

1500701-68.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal, porquanto descrita a conduta do furto com perfeição, da qual o réu se defendeu com amplitude.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo auto de avaliação (fls. 22), pelo auto de entrega (fls. 23). O laudo de fls. 246/256 comprova a qualificadora para ingresso na imobiliária.

A qualificadora de concurso de agentes decorre da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500701-68.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500701-68.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212673/2022 - 01º D.P. AMERICANA, 26575000 - 01º D.P.

AMERICANA, 2212673 - 01º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO ALVES DE MATOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

RODRIGO ALVES DE MATOS e MARCOS LEONARDO DE FALCO estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, ambos do Código Penal, acusados de no dia 05 de agosto de 2022, às 03h35, no estabelecimento comercial "Parathi Imóveis", localizada na Rua Gregório Luchiari, 397, bairro São Vito, nesta cidade, agindo em concurso e unidos pelo mesmo desígnio, terem subtraído, para eles, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, um aparelho de telefone celular da marca "Samsung" e R\$ 8,85 (oito reais e oitenta e cinco centavos), pertencentes à empresa-vítima "Parathi Imóveis", representada por Rafael Luiz de Andrade.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Recebida a denúncia em 22 de agosto de 2022 (fls. 144), os réus foram citados (fls.

162 e 164).

Respostas à acusação no prazo legal (fls. 172/176 e 197/205).

Em prosseguimento à instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns. Ao final, os réus foram interrogados.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação requereu a conversão do julgamento em diligência para juntada do laudo pericial de local. No mérito, pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria, em concurso de agentes. Discorre sobre pena e regime (fls. 268/271).

Certificada a juntada do laudo, ao depois a acusação reiterou os memoriais (fls. 272 e 275).

A Defesa de Marcos em memoriais, alegou ser nulo o processo. Reclama de ilícita atuação da Guarda Municipal, fora de suas atribuições, comprometendo a ação penal. No mérito, pugnou pela absolvição, atipicidade da conduta. O valor total dos bens subtraídos pelos acusados seria insignificante. Subsidiariamente, desclassificação do crime para furto simples, na modalidade tentada, excluindo a agravante do rompimento de barreira. Redução da pena, no grau máximo. O crime não se consumou. Não havia prova do concurso de agentes. Para o caso de condenação, pena mínima, compensação entre as agravantes circunstâncias agravantes com a confissão espontânea, com benefícios (fls. 280/286).

A defesa de Rodrigo reclamou idêntica absolvição. Ilegalidade de busca realizada por guarda civil, com nulidade processual. No mérito provas insuficientes.

Justificou os bens dentro do veículo e não se juntou filmagem de câmera.

Afastamento do concurso de agentes. Para o caso de condenação, requer a redução máxima pela tentativa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime brando e detração da pena (fls. 287/293).

É o relatório.

DECIDO.

Rejeito a arguição preliminar.

A qualquer do povo é dada a prisão em flagrante, em especial aos guardas civis, que estavam no exercício regular de função, conforme relato, com patrulhamento em praça pública.

Na jurisprudência recente do E. TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL Ação Penal Preliminar Alegação de nulidade da prisão em flagrante efetuada por integrantes da guarda municipal Inocorrência Qualquer pessoa, no exercício da cidadania, pode efetuar prisão em flagrante Dicção do art. 301 do Código de Processo Penal Conquanto a guarda municipal não esteja investida de atividade de polícia preventiva, pode atuar em caráter secundário na pacificação social, prevenção e inibição da prática delitiva, mormente quando ocorrida em locais e condições que estão sob sua esfera de proteção Inteligência do art. 5º, incisos III, IV, V, XIV e XVI, da Lei nº 13.022/2014 Preliminar afastada Apelação Criminal nº 1502519-56.2021.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, sessão permanente e virtual da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 26 de outubro de 2022. XISTO RANGEL Relator(a).

De ver que no particular não ocorreram diligências típicas de polícia, como busca domiciliar ou quebra de dados telemáticos, mas de realização de prisão em flagrante, ainda assim quando os servidores públicos municipais desempenhavam função regular, de patrulhamento em vias da cidade.

Até mesmo no C. STF, onde há repercussão geral a respeito do tema instalada (ainda não concluída - EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.

ATRIBUIÇÕES DE GUARDA CIVIL METROPOLITANA. DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES E ALCANCE DA RESERVA LEGAL CONTIDA NO ART. 144, § 8ª, DA LEI MAIOR. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PARÂMETROS OBJETIVOS E SEGUROS PARA NORTEAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO E DE ALCANCE GERAL. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO PLENÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA), em recente voto vencedor do Ministro Luiz Roberto Barroso (que reconheceu ilegalidade na atuação investigativa de guarda civil), foi por ele enfatizado:

"...A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar

a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida." A G .REG. NOS EMB .DECL. NO A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.281.774 SÃO PAULO RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. ROBERTO BARROSO 0 Decisão: A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto pela Defensoria Pública de São Paulo, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido da absolvição do ora agravante, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, que negava provimento ao agravo. Primeira Turma, Sessão Virtual de 3.6.2022 a 10.6.2022.

A questão, pois, está muito distante do que genericamente se procura atribuir como nulidade na atuação da Guarda Civil Municipal, o que se espera seja definido na repercussão geral referida. Sem embargo, há de se distinguir situações, relembrando que o caso dos autos se refere a prisão em flagrante por guarda civil municipal e não de diligências pretéritas e ao depois consumação de prisão em flagrante. Pelo que se depreende dos autos, os réus estavam em situação que exigia intervenção dos agentes da autoridade. Houve acionamento do alarme, alertado pela equipe de monitoramento. Os agentes de autoridade surpreenderam o réu Marcos dentro da imobiliária. O correu dava cobertura, para dar fuga ao comparsa, segundo a acusação.

Havia indicativo de ocorrência de crime, para a realização da prisão em flagrante (não para a busca ou revista, como é a hipótese) assim, sofre atenuação pelo interesse coletivo em se apurar, prevenir e punir a prática de crime.

A abordagem não foi gratuita ou ocasional, mas movida por patrulhamento preventivo. De lembrar, também, que estando o agente de autoridade no regular exercício da função preventiva, exatamente para proteção do coletivo, não carece de mandado para abordar e revistar, segundo o critério da discricionariedade imediata que lhe confere o Estado para cumprir o mister.

Bem daí a regra do artigo 244 do Código de Processo Penal:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Apenas provado despropósito na ação profissional desenvolvida, o que não ocorreu e foi produzido em termos de prova, pode dar ensejo à nulidade perseguida pela Defesa.

Incontroverso, também, que o policiamento preventivo e a revista imediatamente realizada resultaram em apreensão de instrumentos utilizados no crime (ferramentas), dinheiro e celular, a par de ter um televisor separado para ser retirado, sobre o sofá da imobiliária vítima.

Não se tratou de busca investigativa, quando o objetivo estatal, por meio de seus agentes, é relacionar a pessoa abordada a crime ocorrido, exigindo-se então a fundada suspeita a legitimar a ação.

Diversamente, como é o caso destes autos, a busca preventiva se dirige a fundada suspeita, portanto, funciona como garantia de que a pessoa não será, aleatoriamente, relacionada à prática de uma infração penal investigada, sem possuir relação com o fato.

Já a busca preventiva visa manter a ordem pública, evitar ilícitos, dar efetividade às leis e se dirige a todos, indistintamente.

Exigir fundada suspeita sem distinguir a finalidade da ação estatal é desconsiderar texto legal vigente, além de inverter a consideração de presunção de legitimidade dos atos realizados pela administração pública e seus agentes, para considerá-la em regra abusiva.

No mérito, a ação penal é procedente, em parte.

Na fase policial, o réu Marcos silenciou (fls. 07).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lanço aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Já o corréu, também no inquérito, negou a prática de crime. Garantiu que apenas estava repousando no interior de seu veículo GM/Kadett, de cor vermelha, placas CFI-1534, defronte a imobiliária Parathi. Não sabia que a imobiliária tinha sido invadida por Marcos, pessoa que alegava desconhecer. As ferramentas encontradas em seu veículo eram os seus instrumentos de trabalho (fls. 06).

Em Juízo, Marcos alegou que estava dentro da imobiliária, sob efeito de álcool e de crack. Era dependente químico, estava em abstinência. Para entrar, arrombou três cadeados. A porta de blindex já estava aberta. Negou ter danificado a porta. Morava em Santa Bárbara d'Oeste, há três dias recaiu no crack, não ia trabalhar, nem voltava para a casa. Conhecia o Rodrigo há poucos dias, do bairro. Tinha se encontrado com ele por duas vezes, usavam drogas juntos. Pediu uma carona para o Rodrigo, 'até lá em cima'. Entrou e a polícia já o abordou, dentro da imobiliária. Rodrigo ficou esperando o seu retorno, do lado de fora. Acreditava que o Rodrigo não sabia que iria praticar o furto, tinha comentado com ele que precisava usar drogas. Falou bem antes para o Rodrigo que precisava roubar, faria um furto, para usar mais drogas. Rodrigo permaneceu esperando do lado de fora. As ferramentas utilizadas para entrar não estavam com o Rodrigo. As ferramentas que estavam no carro dele não foram usadas. Usou apenas um alicate, que estava fora do local, ficou pendurado na corrente. Estava sob o efeito de entorpecentes, em estado de abstinência, não tinha noção do que estava fazendo. Os guardas apreenderam o seu celular, o valor de R\$ 8,80, que estava no seu bolso, um cachimbo, um isqueiro e um maço de cigarros. Esses pertences não eram da imobiliária. Comentou com o Rodrigo que precisava arrumar dinheiro para usar droga, que iria furtar, bem antes do acontecido. Rodrigo não tinha ciência de que ocorreria o furto naquele momento. Estava arrependido. Rodrigo, de sua vez, explicou que estava dentro do carro, dormindo. Tinha um alicate dentro do seu carro sim, mas não era a ferramenta que eles estão falando. Não tinha ligação nenhuma com o Marcos, não o conhecia.

As versões dos réus, a par de contraditória entre elas, não convencem.

Rafael Luiz de Andrade, representante da imobiliária, adiantou que não tinha condições de proceder ao reconhecimento dos acusados. Esclareceu que por volta das 03 horas dormia em sua casa e recebeu o alerta da empresa que faz o monitoramento da imobiliária. Foi até o estabelecimento, viu a viatura e um carro parado, na frente do comércio. Tomou conhecimento de que o homem que estava no carro foi abordado. Surpreenderam um rapaz que estava dentro da imobiliária. Para ingressar

no local estouraram dois cadeados e uma fechadura. A porta de vidro era só dar um tranco forte que ela abria. Abriu a porta para os policiais. Quando eles informaram que havia uma pessoa no interior da imobiliária, saiu. Não conversou com o homem, que estava dentro do estabelecimento. O outro rapaz estava dentro do veículo Kadet, na rua, em uma distância de dois imóveis, bem ao lado. A câmera de vigilância não pegou a imagem do carro. Puxaram as imagens internas, pelas gravações, viram que os criminosos utilizaram um alicate, grande, para estourar os cadeados. Esse alicate foi encontrado dentro do carro, em que um dos homens dormia. A imagem somente permitiu identificar um dos envolvidos, aquele que estourou os cadeados. Além dos danos, não teve outros prejuízos, apenas para conserto do que foi quebrado. Thabata Regina de Faria Almeida dos Santos, guarda municipal, recordou-se de que foi 'pago' via controle, alarme acionado. Foram até o estabelecimento, tinha um veículo próximo, estacionado. A imobiliária tinha porta e grade, identificou que os cadeados estavam estourados. Ouviu um barulho vindo de dentro da imobiliária. Observou que havia um veículo nas proximidades, em que o ocupante fingia que estava dormindo. Realizaram busca veicular, localizaram os objetos utilizados para quebrar o cadeado. A grade da imobiliária havia sido estourada. O dono da imobiliária esteve no local. Como tinha grade, a porta de blindex estava fechada.

Aparentemente, não havia sinais de arrombamento, mas como escutou um barulho, desconfiava que tinha alguém lá dentro. Quando o proprietário abriu a porta, surpreenderam outro homem, identificado como Marcos, que estava em um corredor que dava acesso ao banheiro. Marcos foi revistado, com ele localizaram uma sacola, com moedas. Imediatamente, ele confessou que havia subtraído as moedas de dentro de uma gaveta da imobiliária. Confirmava que foram rompidos três cadeados e foi danificado o gradil da porta. O comparsa dele era o rapaz que estava no veículo, no lado de fora da imobiliária, identificado como Rodrigo. Marcos disse que conhecia o Rodrigo, não se recordava dele ter dito que eles estavam juntos. Ao ser questionado, o Rodrigo disse que dormia no veículo e que conhecia o Marcos. A televisão de parede havia sido retirada, ela estava no sofá, para ser retirada. A vítima informou que tinha muitas moedas nas gavetas. A imobiliária estava toda revirada.

Reginaldo Araujo de Melo, outro guarda, ratificou a versão da colega de farda, harmônica e coerentemente. Destacou que o controle da gama foi acionado por uma empresa de segurança e monitoramento. Na ocasião o alarme foi acionado. Diante das informações, a equipe deslocou-se até o endereço informado, constataram três cadeados danificados, com a grade. A porta de vidro, de blindex, estava fechada. Foi feito contato com o proprietário para abrir o estabelecimento. A GCM Thabata ouviu um barulho no interior do estabelecimento. Enquanto aguardavam a chegada do proprietário, avistaram um veículo do lado, próximo ao numeral 423. O condutor foi abordado, realizaram os procedimentos e localizaram alguns objetos, todos no interior do veículo. Após o proprietário abrir o estabelecimento encontraram outro homem, dentro do comércio, em um corredor que dava acesso ao banheiro. Durante a revista, localizaram uma sacola contendo moedas. De pronto ele confessou o delito. No sofá do estabelecimento, foi localizado um aparelho televisor, já preparado para ser retirado do local.

A prova é boa e convincente, pois, tanto quanto a ocorrência do crime quanto a autoria.

Em plena madrugada, os réus rumaram ao estabelecimento comercial, evidentemente fechado e enquanto Rodrigo aguardava no carro, o corréu se dispôs a arrombar cadeados e entrou no estabelecimento. Chegou a se apoderar de moedas que estavam na gaveta e deslocou televisor e o separou, com outros bens.

Houve acionamento do alarme, empresa de segurança alertou a guarda civil municipal e os servidores que estavam em patrulhamento por vias públicas, avistaram o carro em condições suspeitas e o comércio com cadeados arrombados. Comunicaram a vítima, que abriu o seu comércio e nesse meio tempo a guarda civil ouviu barulho no interior. E, de fato, o corréu lá foi surpreendido, nas condições e circunstâncias já referidas.

Instados, os réus admitiram ser pessoas conhecidas, deram versões desencontradas e no carro tinha ferramentas, todas hábeis ao rompimento de obstáculo verificado.

Assim, restou apurado que Marcos rompeu três cadeados e danificou o gradil da porta, para ingressar no estabelecimento, com o objetivo de subtrair bens e objetos de valores. Rodrigo aguardava ao lado de fora, no interior de um veículo automotor.

Rafael, representante da imobiliária, destacou que as imagens capturadas pela câmera apontavam para a ferramenta utilizada no furto e coincidentemente apreendida no veículo ocupado pelo réu Rodrigo Alves de Matos.

Importante também, crime de furto, a consideração de que os bens foram apreendidos com os réus, cabendo a eles a apresentação de escusa convincente para a posse.

Tal apreensão, por si só, já justifica o entendimento no sentido de que "Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório" (JTACrSP 66/410).

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E quanto a valia das declarações da vítima, em crime contra o patrimônio:

"A palavra da vítima é valiosa e não pode ser desconsiderada, máxime em crimes patrimoniais, quando incide sobre o proceder de desconhecidos em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes." (TACrimSP: RJTACrim 47/268).

O bem subtraído tinha valor patrimonial e utilidade para a vítima.

Ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial". E prossegue: "É praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja efetivo desfalque do patrimônio alheio" (Manual de Direito Penal, 21ª. Ed., vol. I e II, pp 118/119 e 225/226).

Na jurisprudência, em voto lapidar do E. Des. Francisco Galvão Bruno, exarado nos julgamentos dos recursos de apel. n. 990.09.291678-5, da Comarca de S. José do Rio Preto, em 15.4.2010, e 990.10.079006-4, da Comarca de S. Paulo, em 29.7.2010, verbis, que coloca em dúvida a possibilidade de se reconhecer tal tese:

"(...) Não há (...) possibilidade de se acolher a tese de atipicidade da conduta porque o princípio da insignificância ou bagatela não pode ser aplicado às hipóteses típicas penais previstas em lei (...) não se infere de nenhum dispositivo do ordenamento pátrio a exclusão de tipicidade baseada no valor ínfimo (ou qualquer valor) do objeto furtado. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, com

critérios de aplicação altamente subjetivos. E estabelecer limites para a aplicação do princípio da insignificância não é uma tarefa simples, pois exige juízo de valoração sobre a gravidade do fato, o que pode abrir caminho para arbitrariedades, insegurança jurídica e até conivência com a impunidade. Desta maneira, o valor econômico do bem objeto do crime pode ser levado em consideração, mas não como único parâmetro para fixação da pena e muito menos para exclusão da tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o valor do bem, mas a conduta do agente. Certamente não estamos falando de um crime gravíssimo, mas também não se pode dizer que a ação delituosa foi insignificante ao ponto de não merecer tanto trabalho e custo do Estado (...)"

Não impressiona o fato de apenas moedas terem sido apreendidas com Rodrigo, que estava em plena ação criminosa, pois já tinha disposição para levar até televisor, deslocado e colocado em sofá, para esse propósito.

As moedas não representam o valor do prejuízo, que aliás não ocorreu porque os agentes foram presos em flagrante, evitando-o.

As versões dos acusados, em suma, estão isoladas nos autos.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constitui uma exceção de defesa e, como tal, cabe ao inculpatado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

A respeito, já se decidiu que "de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o alibi apresentado." (STJ, 5ª Turma, Habeas Corpus nº 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).

Não é de passar ao largo também a verificação de que os réus possuem outros antecedentes, crimes contra o patrimônio, revelando ideação em praticar crimes do jaez, caracterizando a alegação de insignificância busca de respaldo legal para delinquir.

Favorece aos réus apenas a constatação de que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos acusados (efetiva prisão pela guarda municipal).

Aplicável à hipótese o artigo 383 do Código de Processo Penal, porquanto descrita a conduta do furto com perfeição, da qual o réu se defendeu com amplitude.

A materialidade foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), pelo auto de avaliação (fls. 22), pelo auto de entrega (fls. 23). O laudo de fls. 246/256 comprova a qualificadora para ingresso na imobiliária.

A qualificadora de concurso de agentes decorre da fundamentação e da prova oral.

As condições pessoais dos réus obstam regime brando e substituição por restritivas de direitos.

Fixação das penas.

Os réus registram duas condenações anteriores. Apenas uma condenação será considerada para reincidência (RODRIGO vg. Processo nº 0007158-64.2014.8.26.0019 - 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 155 § 4º, I, II do Código Penal; com trânsito em julgado para a Defesa em 02/12/2014, pena cumprida ou julgada extinta em 28/06/2017 e MARCOS vg. Processo nº 1502729-77.2020.8.26.0533 - 2ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, incurso no (Art. 155 § 2º § 4º, I, IV c/c Art. 14, II c/c Art. 61 "caput", II, "j" todos do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 25/04/2022). A outra, embora apta para o mesmo fim, para evitar 'bis in idem' será considerada como circunstância judicial, evidenciando os seus maus antecedentes, de há muito. Observo também a duplicidade de qualificadoras, concurso de agentes e rompimento de obstáculos, onde uma delas qualifica a infração, enquanto a outra deve ser adotada como circunstância judicial desfavorável, reveladora do intenso desiderato de levar a cabo a consumação da infração.

Assim já se pacificou que a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado.

"O uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem, nem viola a Súmula 241/STJ.". (TJDF APR 10250110093863; no mesmo sentido, STJ, HC 306.222/RS).

"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial, prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 465-466).

Por essas fundamentações, exaspero as penas em 1/5 (um quinto).

Na segunda, há reincidência específica (RODRIGO vg. Processo nº 0009358-39.2017.8.26.0019 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 157 § 2º, I c/c Art. 61 "caput", I c/c Art. 65 "caput", III, "d" todos do Código Penal; com trânsito em julgado para a Defesa em 29/01/2018 e MARCOS vg. Processo nº 0001338-93.2022.8.26.0533 - 1ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste/SP, incurso no Art. 155 § 2º § 4º, I, IV c/c Art. 14, II c/c Art. 61 "caput", II, "j" todos do Código Penal; com trânsito em julgado para a Defesa em 25/04/2022). Embora o réu Marcos tenha confessado a prática do furto, a atenuante da confissão não pode ser acolhida, na medida que ele tentou isentar o seu comparsa de responsabilidade, não se justificando a compensação, na hipótese, já que a um só tempo queria se beneficiar indevidamente do afastamento da circunstância qualificadora. Por essa fundamentação, aumento as penas na segunda fase em 1/6 (um sexto), para ambos os réus.

Ainda na última fase, pela tentativa e considerando que a ação não se consumou, reduzo a pena em metade, pois os réus não chegaram a se afastar do lugar do crime com a "res", mas provocaram danos significativos, assim a definindo.

É de se impor o regime inicial fechado, pela específica reincidência e circunstâncias que nortearam a pena base (circunstâncias judiciais desfavoráveis). Reincidentes específicos, não se pode substituir a privativa de liberdade por restritivas de direitos. Idem para o sursis.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra RODRIGO ALVES DE MATOS e MARCOS LEONARDO DE FALCO condenando-os, cada qual, às penas de um (01) ano, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, regime inicial fechado e sete (07) dias-multa piso, por infração ao artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. artigos 61, I, todos do Código Penal. Observe-se a impossibilidade de aplicação do benefício do artigo 44 do CP por se cuidar de reincidência específica (passagens por crimes patrimoniais) e por haver prova de que a substituição não seria devida para a repreensão e retribuição da conduta, mercê das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Idem para o sursis (reincidência).

Não existem provas dos danos sofridos ou reclamação de prejuízo, provado, com instauração do contraditório a respeito. Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório.

Isento os réus das custas, assistidos por defensores nomeados e presumidas as necessidades (fls. 145 e 191).

Vinculado o objeto apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, autorizando destruição ou doação, acaso inservíveis ou sem valor econômico. Já encerrada a instrução, não mais prevalecem os motivos que deram ensejo à prisão cautelar, o que se considera em face do tempo da prisão e na Recomendação 62 do CNJ. Já cumpriram lapso temporal razoável para preenchimento de requisito objetivo e eventual progressão, o que deverá ser analisado em Execução Criminal.

Faculto aos réus recurso em liberdade, expedindo-se alvarás de soltura.

Após o trânsito, inscrevam-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 1º de dezembro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA